

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙から、甲宛てに荷物を発送したので受け取ってほしいと依頼され、もしかしたら同荷物には覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物が入っているかもしれないと思いながら、乙が覚せい剤を忍び込ませた荷物を受け取って所持していた。この場合、甲には、覚せい剤取締法違反（覚せい剤所持）の罪が成立する。
2. 甲と乙は、丙に暴行を加えて傷害を負わせることを共謀したところ、乙において、丙に暴行を加えている最中に興奮して殺意を生じ、丙を殺害した。この場合、甲には、傷害罪の共同正犯が成立する。
3. 甲は、乙が第三者から窃取した指輪を、もしかしたら盗品かもしれないと思いながら、あえて有償で乙から譲り受けた後、同指輪に乙と同じイニシャルが刻み込まれていることに気付き、盗品ではないと確信するに至った。この場合、甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。
4. 甲は、わいせつな映像を録画したDVDを、あらかじめその内容を再生して確認し、この程度ではわいせつ物には当たらないと考えて、多数の者に販売した。この場合、甲には、わいせつ物頒布罪が成立する。
5. 甲は、乙を殺害しようと考え、乙の背部を狙って拳銃の弾丸を発射したところ、同弾丸が乙ではなく、乙の隣にいた丙の腹部に当たり、丙を死亡させた。この場合、甲には、乙に対する殺人未遂罪と丙に対する重過失致死罪が成立する。

No437

R1-11

故意

正解

2、5 (順不同)

正答率

83%

1 正しい

最決平2.2.9 (百選I40事件)は、「被告人は、本件物件を密輸入して所持した際、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない」としている。よって、甲には覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪が成立する。

2 誤っている

最決昭54.4.13 (百選I92事件)は、「殺意のなかつた被告人aら6名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」として、軽い罪の故意しかなかった者については、構成要件の重なり合う限度で軽い罪の共同正犯の成立を認めている。また、判例は、結果的加重犯が成立するためには基本犯の実行行為と重い結果との間に因果関係があれば足り、重い結果についての過失は必要ではないとしている。このような立場からは、基本犯の共同実行と重い結果との間に因果関係が存在する以上、共同して重い結果を惹起したといえるから、全員が重い結果について責任を負うことになる。よって、甲には傷害致死罪の共同正犯が成立する。

3 正しい

最判昭23.3.16 (百選I41事件)は、赃物故買罪(現盗品等有償譲受け罪)について、「その故意が成立する為めには必ずしも買受くべき物が赃物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は赃物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りる」としている。本記述で甲は、譲り受けた時点においては、もしかしたら盗品かもしれないとの認識を有している。よって、盗品等有償譲受け罪の故意が認められる。よって、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。

4 正しい

最大判昭32.3.13 (百選I47事件)は、「175条の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない」としている。甲は、内容を再生して確認したうえで販売しているから、問題となる映像の存在の認識及びこれを頒布販売することの認識はあり、わいせつ物頒布罪の故意が認められる。よって、わいせつ物頒布罪が成立する。

5 誤っている

最判昭53.7.28 (百選I42事件)は、「人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかつた人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべきである」としている。その理由として、判例は、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りる」(法定的符合説)ということを挙げている。甲は、乙という人を殺害する意思を有しているから、それにより丙という人を死亡させた場合でも、丙に対する殺人の故意が認められる。よって、甲には乙に対する殺人未遂罪と丙に対する殺人罪が成立する。